

1517223-52.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996). 3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de provas obtidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517223-52.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517223-52.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193062/2021 - DEL.SEC.5ª LESTE, 19091477 - DEL.SEC.5ª LESTE, 84/21/200 - DEL.SEC.5ª LESTE, 2193062 - DEL.SEC.5ª LESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALY COULIBALY

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

WALY COULIBALY, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Ele teria, no dia 16 de julho de 2021, por volta de 16h10min, na Rua Alegre, nº 109, Carrão, nesta Capital, trazido consigo e guardado, para entrega a consumo de terceiros, 68 invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 271,7g; e 20 frascos contendo lança-perfume, com conteúdo líquido de 170ml; substâncias entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 18, laudo de constatação provisória a fls. 22/25).

Por ocasião dos fatos, policiais civis realizavam diligências pela via pública acima mencionada quando visualizaram o denunciado. WALY passou a esboçar nítido nervosismo com a presença policial, o que despertou suspeita nos policiais, decidindo estes pela abordagem. Em revista pessoal, foram localizadas 08 porções de maconha, além da quantia de R\$ 50,00. Questionado, WALY disse que morava em uma casa naquela rua e confessou que guardava mais entorpecentes em sua residência. Assim, os policiais se dirigiram para a residência do denunciado e, no interior do quarto de WALY, os policiais apreenderam o restante das substâncias entorpecentes, que ali eram guardadas. Interrogado pela autoridade policial, o denunciado optou por permanecer em silêncio (fls. 11).

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, foi ela recebida por despacho no dia 06 de outubro de 2021. Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 94), vindo aos autos, no prazo legal, a resposta à acusação (fls. 96). Inviável a absolvição sumária, designei audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução de causa, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado ouvido ao final, tudo registrado em mídias digitais acostadas aos autos.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade na qual o Ministério Público pediu para que, em primeira fase, a pena seja fixada acima do mínimo legal, em vista da variedade e quantidade de droga; em segunda fase, pleiteou o reconhecimento da agravante referente ao estado de calamidade pública; em terceira fase, pediu o reconhecimento da falta de causas de aumento ou diminuição da pena; e, por fim, pediu para que seja aplicado o regime inicial fechado.

Por seu turno, a Defesa pleiteou a absolvição do acusado, alegando a ilicitude das provas pelo ingresso da residência do acusado em desconformidade com a Constituição Federal. Não sendo esse o entendimento deste juízo, pediu para que a pena base seja estabelecida no mínimo, em razão da primariedade do réu; em segunda fase, requereu o afastamento da agravante relativa ao estado de calamidade pública; na terceira fase, pediu para que seja reconhecida a inexistência de causas de aumento e diminuição da pena; e, por fim, pediu para que seja aplicado regime inicial diverso do fechado.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 05/06; 28/29); o auto de prisão em flagrante (fls. 04; 10); o auto de exibição e apreensão (fls. 18); os laudos periciais (fls. 22/25; 135/136); bem como as folhas de antecedentes do acusado (fls. 38/39; 79/81).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, quanto ao pedido da Dra. Defensora Pública de que o processo seja anulado, com fundamento em violação ao domicílio do réu para constatação dos fatos, incorrendo tal em prova ilícita que contaminou todo o processo, não merece prosperar.

Com efeito, é entendimento pacífico que a violação ao domicílio é permitida em caso de flagrante delito. Nesse sentido:

STF: "DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. 1. A questão controvertida consiste na possível existência de prova ilícita ("denúncia anônima" e prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o processo que resultou na sua condenação. 2. Legitimidade e validade do processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, de "denúncia anônima" dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996). 3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo,

na espécie, o disposto no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. 4. Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito, desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial. 5. Outras questões levantadas nas razões recursais envolvem o revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus. 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 86.082 RS)" (grifo nosso).

Anote-se que o que motivou a entrada dos policiais ao domicílio foi a constatação de que o acusado teria informado possuir mais drogas em casa para o comércio ilícito, o que constituiria o crime de tráfico de drogas.

Ainda que, recentemente, as Cortes Superiores tenham demonstrado maior rigidez quanto a permitir a violação do domicílio, como atestado pela combativa defensora, é certo que, no caso em tela, a motivação da violação ao domicílio foi concreta, não se baseando apenas em hipóteses e suspeitas vagas. Os policiais ingressaram no domicílio do réu, e lá encontraram mais drogas já preparadas para o tráfico ilícito.

Assim, presentes os requisitos mínimos para que os policiais adentrassem à residência do réu, não há que se considerar a preliminar arguida pela defensora. Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada improcedente, uma vez que, a meu ver, os depoimentos dos policiais prestados em sede policial e em juízo apresentam graves inconsistências.

Com efeito, em juízo, ouvidos em 11/11/2021, fls. 125, os dois policiais civis, únicas testemunhas do fato, declararam que no dia da abordagem do acusado, presenciaram o réu vendendo drogas a um usuário de forma bastante clara. Teriam encontrado uma chave no bolso do acusado que os levou até sua residência, próxima a abordagem, local onde o restante do entorpecente foi apreendido.

É nesse sentido que o policial civil, Carlos, declarou que reconhece o acusado de um tráfico de entorpecentes. Recorda-se que a circunscrição do 30º DP faz parte da seccional do depoente. Fizeram o mapeamento e foram a Comunidade Alegre. Entraram em uma rua e visualizaram o acusado a mercancia, pegando algo e entregando algo. WALY, ao perceber a presença da polícia, ficou nervoso. Fizeram a abordagem e encontraram R\$ 50,00 e 7 ou 8 papелotes de maconha. Encontraram uma chave no bolso dele. O acusado disse que reside lá e levou o depoente a sua residência. Lá, dentro da casa, encontraram maconha e haxixe. Não se recorda de outro tipo de entorpecente. WALY admitiu até porque já foi preso por outro policial do 30º DP na mesma prática. O réu é estrangeiro e tem uma postura. Ele admitiu. Disse que é pedreiro, estava desempregado e por isso estava na prática ilícita. O acusado disse que tem família mas o depoente não sabe se a família mora no local. O que pode afirmar é a casa do acusado não possibilita um local adequado para família e não havia indício algum de que ali residia uma família. Recordou-se de uns vidrinhos de lança perfume deviantemente apreendidos. Antes da abordagem, por um momento viu a conduta do acusado na prática. Presenciou o momento em que o acusado vendeu droga a um usuário. A maconha já estava dividida em porções, inclusive a que se encontrava na casa. O usuário não foi qualificado porque foi na direção contrária a dos policiais. Acredita que a casa dele fica a mais ou menos uns 10 metros do local de onde ele foi preso. Não houve qualquer declaração de autorização do acusado para que ingressassem na residência. Somente foram a casa do acusado porque ele disse que lá havia mais entorpecente. O entorpecente se encontrava em uma caixa de sapato, embaixo da pia. Ninguém investiu contra a polícia e o acusado não reagiu. Stefan, colega de Carlos, também reconheceu o acusado da mesma prática. O fato foi deflagrado através de uma operação determinada pela Autoridade Policial. Nesse caso, no local já havia ocorrido uma prisão em flagrante e pelo que sabe o réu já foi preso em flagrante no local. Chegou a ver a fotografia do acusado que foi enviada de outro colega de uma outra prisão. Quando entraram na rua, o acusado conversava com outro rapaz e a ele entregou algo. Acelerou e então o rapaz andou em direção oposta e o acusado entrou em um bar e o depoente e seu parceiro entraram atrás. Ele foi preso dentro do bar. Ele estava com algumas porções, cinco, de maconha e um celular. Não se recorda de dinheiro. Deram voz de prisão. Perguntaram onde estavam as drogas e ele negou. Os demais policiais fizeram uma busca mas nada

foi localizado. Ele ficou detido conversado com outros policiais. Ele acabou indicando onde era a casa dele. Entraram na casa mediante autorização dele. Ele disse que era pedreiro. A casa não aparentava ser habitada por família. A casa estava muito suja. Sabe que o entorpecente foi encontrado em uma caixa de tênis. Permaneceu na detenção do acusado. Somente se recorda da maconha. Não lembra se havia cocaína ou lança perfume. A princípio ele negou e se disse usuário. Ele admitiu que estava no tráfico no momento que levou os policiais a casa dele. No bar uma senhora que se identificou como proprietária. Ele não tentou fugir e não foi agressivo. Não se recorda se ele declarou a existência de entorpecente antes ou depois de ser algemado. Sabia que ele tinha mais entorpecente porque o viu vendendo o entorpecente. O usuário não foi localizado porque após a detenção do acusado, tentou localiza-lo, mas isso não ocorreu. Ele morava há uns 10 metros do local de sua prisão. Sem a indicação do acusado não seria possível localizar o restante da droga.

É certo que o depoimento dos policiais, em crimes de tráfico ilícito de entorpecentes tem grande valor. Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua presunção.

Contudo, na medida em que apenas dois policiais prestaram depoimento, é preciso que eles sejam harmônicos e não deixem margem para dúvidas o que, a meu ver, não aconteceu no presente caso.

Com efeito, pela leitura dos depoimentos desses mesmos policiais prestados em solo policial, em momento algum eles mencionam ter presenciado o acusado em plena atividade de mercancia do entorpecente ou sobre a chave que encontraram em seu bolso e que seria de sua residência onde o restante do entorpecente foi localizado. Essas informações seriam e são de grande relevância e jamais poderiam ter sido esquecidas pelos policiais civis ao serem ouvidos no flagrante ou deixadas de lado pela autoridade que os ouviu em declarações.

É o que se depreende da análise de fls. 13 e 14.

A fl. 13, o policial Carlos Antonio foi ouvido e declarou:

"Realizavam diligências pela área da 5ª Seccional, quando visualizaram na rua Alegre, o indivíduo ora identificado como WALY COULIBALY, o qual ao perceber a presença policial passou a demonstrar nervosismo exacerbado. continuaram a observar o suspeito, e então decidiram abordá-lo. Em busca pessoal, localizaram no interior do bolso da calça, (08) oito substâncias aparentando ser "maconha", e R\$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, o mesmo não portava documento, em conversa com o indigitado este confessou que morava naquela via no numeral 109 e, que, em sua casa que trata-se de comunidade armazenava mais uma quantidade de substancias semelhantes. Dirigiram-se ao local onde o indiciado franqueando-lhes a entrada e mostrou -lhes no quarto em que dorme mais substâncias semelhantes a Maconha,(60) porções e (20) vinte frascos com substância aparentando ser "lança perfume", bem como naquele local WALY pegou seu passaporte que estava naquele quarto, diante disso deu voz de prisão ao indiciado onde o mesmo foi trazido para unidade policial e apresentada a ocorrência a autoridade policial"

O policial Stefan, também ouvido, nada declara sobre ter presenciado o réu em efetiva atividade de venda de entorpecentes. Abaixo transcrevo o depoimento de fls, 14:

"Nesta data, na companhia do policial Ricardo realizavam diligências pela área da 5ª Seccional, a fim de coibir o tráfico de drogas na região, momento em que visualizaram na Rua Alegre, o indivíduo posteriormente identificado como WALY COULIBALY, o qual ao perceber a presença da viatura policial passou a demonstrar nervosismo. Continuaram a observar o suspeito, e então decidiram abordá-lo. Em busca pessoal, localizaram no interior do bolso da calça, oito substâncias aparentando ser "maconha", e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, o mesmo não portava documento, em conversa informal este confessou que morava naquela via no numeral 109 e, que, em sua casa que trata-se de comunidade armazenava mais uma quantidade de substancias semelhantes. Dirigiram-se ao local onde o indiciado

indicou, franqueando-lhes a entrada e mostrou -lhes no quarto em que dorme mais substâncias semelhantes a Maconha, (60) porções e (20) vinte frascos com substância aparentando ser "lança perfume", bem como naquele local WALY pegou seu passaporte que estava naquele quarto. Diante dos fatos o Policial Ricardo deu voz de prisão ao indiciado que foi trazido a esta distrital, sendo apresentada a ocorrência a autoridade policial."

Nada foi fotografado pelos policiais, outra medida de grande importância em situações como a que se apresenta nestes.

É preciso que a prova apta a condenação seja extrema de dúvidas o que não ocorre no caso em apreço.

Interrogado em juízo, o acusado Waly declarou ser africano, de Mali. Está aqui desde 2013. Veio sozinho mas está casado com uma brasileira e tem uma filha. É pedreiro diplomado pelo Senai. Já foi condenado por tráfico de drogas. Tem 37 anos. Sobre os fatos, nega. Trabalha em uma empresa no terminal Pinheiros e estava morando em um alojamento em Itupeva. Trabalhava de segunda a sábado. Estava trabalhando nessa época na empresa Englic. No dia dos fatos trabalhou só meio período. Foi liberado e veio a São Paulo para ver a família. Os policiais entraram na casa 10 e a família morava na casa 12. Não tinha chave no bolso e nem a maconha. Não é usuário. Não é traficante. Não confessou nada aos policiais. A esposa foi fazer compras e ficou com a filha. Tinha cinco reais e queria comprar um salgado para filha. Estava saindo com a filha do bar. A filha tem 3 anos e 2 meses. Foi algemado dentro do bar. É trabalhador. Os policiais o levaram para o fundo da viela. Nisso mentiu que nunca havia sido processado. Foi agredido e ferido pelos policiais. Foi ameaçado de morte pelos policiais. Eles disseram que queriam negociar e pediram dinheiro. Carlos e outro policial pediram dinheiro para soltar o interrogando. Disse que não tinha dinheiro. A perna do depoente estava sangrando quando chegou na delegacia. Não quis mostrar. Não foi ao corpo delito. Só foi submetido a exame 15 dias depois que chegou na penitenciária de Itai. Foi agredido com tapas e murros. O delegado não tirou fotografias do interrogando sem roupas. Os policiais quebram a porta para entrar na casa que eles entraram. Nove policiais participaram da ocorrência.

O acusado nega a acusação, dizendo que é trabalhador e que não é usuário ou traficante. Alega que os policiais tentaram negociar, pedindo dinheiro. É claro que ele não comprovou ser trabalhador e um pai de família. E também resta comprovado que já foi condenado por outro crime de tráfico de drogas, praticado no mesmo local.

Mas estas circunstâncias não podem influir o espírito do julgador de forma a complementar a prova do fato, quando esta é frágil e não autoriza o édito condenatório.

Assim, com relação à autoria, tem-se apenas suspeitas fundamentadas pela prisão em flagrante por crime semelhante bem como pela condenação por tráfico de drogas anterior, que ocorreu no mesmo local, conforme nos demonstra o B0 juntado a fls. 30/34.

Diante de tudo isso, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, outro não pode ser o decreto senão absolutório, até porque, como ensina Júlio Fabbrini Mirabete, "em decorrência do princípio do estado de inocência deve-se concluir que: (...) (b) o réu não tem o dever de provar a sua inocência; cabe ao acusador comprovar a sua culpa; (c) para condenar o acusado, o juiz deve ter a convicção de que ele é responsável pelo delito, bastando, para a absolvição, a dúvida a respeito da sua culpa (in dubio pro reo)". (MIRABETE, Julio Fabbrini, Processo Penal, Atlas, São Paulo, 2007, pgs. 23/24).

De se notar, portanto, que não foram produzidos elementos de prova suficientes que efetivamente apontassem a autoria do delito descrito na inicial. Assim, entendendo de rigor sua absolvição pelo crime que lhe foi imputado, até mesmo por que:

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

E mais, "ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ac. un. da 6a. Câm., de 20-4-76, na Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel. GERALDO FERRARI, idem, pág. 319).

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, absolvo WALY COULIBALY, nascido em 01/01/1985, filho de Traore Arabe e Coulibaly Kondjiri, das imputações que lhe são dirigidas, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Isentos de custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA